

현대 위험구조에서 형사책임 귀속 기준의 전환

- 실행 중심에서 통제 중심으로 -

최애리* · 강양구**

차 례

I. 서론	IV. 위험구조에 대한 규범적 통제로서의 행위
II. 전통적 행위개념의 전개와 실행 중심 구조	V. 인공지능 환경에서 드러난 체계적 긴장과 행위개념 재정위의 필연성
III. 행위개념과 객관적 귀속 이론 사이의 구조적 긴장	VI. 형사정책적 함의
	VII. 결론

【국문초록】

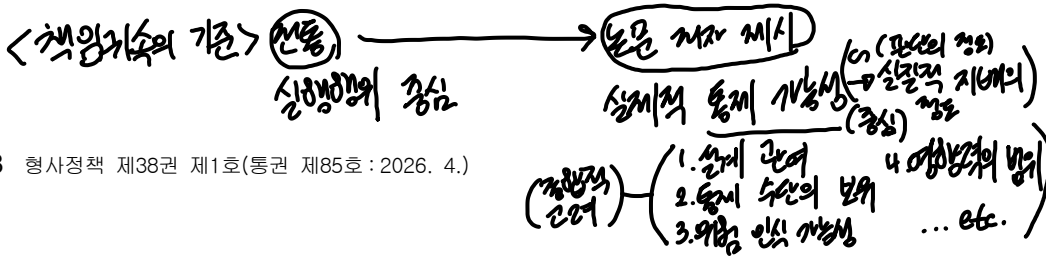
본 논문은 자율주행, 인공지능 등 기술적 매개가 개입된 현대 위험구조에서 전통적인 형사책임 귀속 기준이 일정한 한계를 드러낼 수 있다는 문제의식에서 출발한다. 기존 형법 체계는 행위를 의사에 의해 지배되는 신체적 실행을 중심으로 이해하고, 책임 또한 결과 발생과 직접적으로 연결된 실행행위를 중심으로 구성해 왔다. 그러나 이러한 구조에서는 위험의 규범적 평가는 주로 객관적 귀속 단계에서 이루어지는 반면, 행위는 여전히 물리적 실행의 계기로 이해되는 이원적 구도가 형성된다. 그 결과 행위단계는 형식적 전제로 축소되고, 귀속단계에 책임 판단의 실질적 내용이 집중되는 구조적 불균형이 발생한다.

이와 같은 구조는 전통적 범죄유형에서는 일정 부분 기능해왔다. 그러나 위험이 설계, 조직, 운영, 감독 등 복합적이고 다층적인 조건 속에서 형성되는 현대사회에서는 설명 범위에 한계가 발생할 수 있다. 특히 인공지능이 의사결정 과정에 실질적으로 개입하는 경우, 결과 발생이 인간의 직접적 신체운동과 분리되면서 실행행위를 중심으로 한 책임귀속 구조만으로는 위험형성과 책임 사이의 관계를 충분히 설명하기 어려운 상황이 발생할 수 있다.

이에 본 논문은 책임귀속의 기준을 실행행위가 아니라 위험형성과정에 대한 실제적 통제 가능성으로 재정립할 필요가 있음을 제시한다. 특히 통제 가능성을 단순한

* 최애리 (Choi, Ae Ri), 제 1저자, 미국변호사, 법학박사

** 강양구 (Kang, Yang Koo), 교신저자, 공학박사, 성균관대 겸임교수



78 형사정책 제38권 제1호(통권 제85호 : 2026. 4.)

보조적 고려요소가 아니라 책임귀속 판단의 중심 기준으로 위치시키고, 이를 설계 관여, 통제 수단의 보유, 위험 인식 가능성, 영향력의 범위 등 복수 요소를 종합적으로 고려하는 판단 구조로 정식화한다. 이때 책임귀속은 단순한 영향력의 존재가 아니라 위험형성 구조에 대한 실질적 지배의 정도에 따라 판단될 필요가 있으며, 실질적 통제 가능성이 인정되는 범위 내에서 제한적으로 설정될 필요가 있다.

나아가 이러한 통제 중심 접근은 기존 형법 이론과 단절되는 것이 아니라, (Roxin의 행위지배 이론, 간접정범, 부진정부가위범 논의 등에서 이미 나타나고 있는 통제 개념을 재정렬·확장하는 것임을 논증한다. 이를 통해 정범과 공범의 구별 역시 실행행위의 외형적 분담이 아니라 위험형성과정에 대한 통제의 정도와 구조적 지위를 중심으로 재구성될 필요가 있음을 제시한다. 또한 이러한 기준은 위험의 예견 가능성과 통제 가능성을 중심으로 과실 판단과도 연결됨으로써, 형사책임의 정당화 구조를 보다 일관된 방식으로 설명할 수 있는 이론적 틀을 제공한다.

결론적으로 본 논문은 행위개념을 단순한 실행의 계기가 아니라 위험형성 구조에 대한 통제관계의 관점에서 재정립함으로써, 형사책임 귀속의 기준을 실행 중심에서 통제 중심으로 보완·재정렬하여, 기술환경의 변화 속에서도 책임 귀속의 범위와 기준을 정교하게 설정할 수 있는 이론적 방향을 제시한다.

이동할 때 처벌법에서도 내가 찾아온 방향성

→ 정범 VS 공범

정범
실행행위 대상적 분담
(개행명칭중)
1. 통제의 정도
2. 구조적 지위

주제어 | 행위개념, 위험형성 통제, 책임귀속, 정범·공범 구별, 과실, 객관적 귀속, 인공지능

I. 서론

형사책임은 특정 결과를 누구에게 귀속시킬 수 있는가에 대한 규범적 판단이다. 전통적으로 이러한 판단은 결과 발생과 직접적으로 연결된 행위자의 실행행위를 중심으로 이루어져 왔다. 그러나 대규모 조직, 복잡한 기술시스템, 그리고 인공지능과 같은 기술적 매개가 결합된 환경에서는 결과 발생이 단일한 행위자의 물리적 실행으로 환원되기 어려운 양상을 보인다. 이와 같은 상황에서는 결과 발생의 원인을 특정 시점의 실행행위에만 결부시키는 기존의 책임 판단 방식이 충분한 설명력을 갖는지에 대한 의문이 제기된다.

전통적 형법이론은 행위를 범죄성립의 출발점으로 설정하고, 이를 중심으로 구성요건 해당성, 위법성, 책임이라는 단계적 구조를 형성해 왔다. 그러나 행위는 구성요건 해당성 판단의 전제로서 주로 실행행위의 존재를 확인하는 기능을 중심으로 이해되는 경향이 있으며, 위험에 대한 규범적 평가는 객관

적 귀속 단계에서 보다 집중적으로 이루어지는 측면이 있다.¹⁾ 이로 인해 행위단계는 규범적 판단을 직접적으로 담당하기보다는 형식적 전제로 기능하고, 귀속단계는 위협의 창출과 실현, 책임 주체의 특징에 관한 판단을 폭넓게 수행하는 구조가 형성되어 왔다고 볼 수 있다. 이러한 구조는 전통적 범죄유형에서는 일정 부분 기능해 왔다. 그러나 위협이 구조적으로 형성되는 현대 사회에서는 책임 공백이나 책임 귀속의 불명확성이라는 문제를 야기할 가능성이 있다. 이러한 점은 행위단계가 단순히 실행의 존재를 확인하는 기능에 한정된다는 의미라기보다, 규범적 판단이 체계상 귀속단계에서 보다 집중적으로 이루어져 왔다는 구조적 특징으로 이해될 수 있다.

이와 같은 구조적 특징은 특히 위협이 단일한 행위자의 실행이 아니라 다층적인 구조 속에서 형성되는 경우에 더욱 두드러진다. 전통적 형법이론 역시 작위와 부작위, 행위지배, 의무위반, 객관적 귀속 등을 통하여 행위와 책임의 관계를 정교하게 다루어 왔다. 다만 이러한 이론적 발전에도 불구하고, 위험형성이 구조적으로 이루어지는 상황에서는 결과 발생의 직접적 계기와 그 이전 단계의 위험형성 조건 사이에 간극이 발생할 수 있으며, 이는 책임 판단의 기준을 어디에 둘 것인가라는 문제를 새롭게 제기한다.

이러한 구조적 맥락에서 보면, 행위단계가 형식적 전제로 기능하고 귀속단계에 규범적 판단이 집중되는 구조는, 전통적 범죄유형에서는 일정 부분 기능해 왔다고 평가할 수 있다. 그러나 위협이 구조적으로 형성되는 현대 사회에서는 이러한 구조가 책임 공백이나 책임 귀속의 불명확성으로 이어질 가능성을 내포한다. 또한 이러한 구조적 불균형은 단순한 이론적 문제에 그치지 않고, 실제 책임 귀속의 실효성과도 밀접하게 연결된다.

행위단계가 형식화되고 귀속단계에 규범적 판단이 집중되는 구조에서는, 결과 발생에 기여한 다양한 행위주체들 사이에서 책임의 분배 기준이 불명확해질 수 있다. 특히 조직적·기술적 환경에서는 위험형성에 기여한 행위가 분산되어 나타난다. 이 경우, 특정 시점의 실행행위만을 기준으로 책임을 판단하는 경우 실질적으로 중요한 통제 주체가 책임 귀속에서 배제되거나, 반대로 제한된 관여를 한 행위자에게 과도한 책임이 부과될 가능성이 있다. 이러한 문제는 형사책임의 정당성과 예측가능성을 동시에 약화시키며, 궁극적으로 형법의 규범적 기능에도 영향을 미칠 수 있다.

1) George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law* (Little, Brown, 1978), 418면.

특히 최근 기술환경의 변화는 이러한 문제를 더욱 선명하게 드러낸다. 인공지능 시스템과 같은 기술적 매개는 의사결정 과정에 깊이 관여하며, 결과 발생이 단일한 실행행위로 환원되지 않는 경우를 증가시키고 있다.²⁾ 그러나 이러한 현상은 특정 기술의 문제라기보다, 위험이 구조적으로 형성되는 현대 사회 전반의 특징이 보다 명확히 드러난 것으로 이해할 수 있다. 따라서 문제의 핵심은 인공지능의 책임주체성 여부에 있는 것이 아니라, 위험형성 구조를 누가 통제하고 있었는지에 대한 평가 기준을 어떻게 설정할 것인가에 있다.

이와 같은 문제의식에 기초하여, 본 연구는 행위개념을 단순한 실행행위가 아니라 위험형성 구조에 대한 규범적 통제의 관점에서 재검토하고자 한다. 이는 기존 형법체계를 전면적으로 부정하거나 새로운 책임이론을 도입하려는 시도가 아니라, 이미 객관적 귀속 이론을 통해 규범화된 위험 개념과의 체계적 정합성을 확보하기 위해 행위개념의 위치와 기능을 재정렬하려는 이론적 작업이다.³⁾ 이러한 재구성은 행위단계·귀속단계·책임단계의 기능을 재정렬하는 방식으로 이해될 수 있으며, 행위단계는 위험형성 구조에 대한 통제 가능성을 평가하는 단계로, 귀속단계는 그 위험의 실현 여부를 판단하는 단계로, 책임단계는 통제 가능성과 비난가능성을 검토하는 단계로 기능적으로 구분될 수 있다.

본 연구는 이러한 이론적 재구성을 통해, 행위개념을 위험형성 구조에 대한 통제 가능성의 관점에서 재정식화하고, 형사책임 귀속 기준을 실행 중심에서 통제 중심으로 재정렬하는 것을 목적으로 한다. 이는 단순한 개념적 논의에 그치지 않고, 책임 주체의 특징, 과실 판단 기준의 재검토, 사전적 위험 통제의 필요성 등 형사정책적 논의에 실질적인 시사점을 제공할 수 있다. 나아가 본 연구는 형법체계 내부에서 행위와 위험, 책임 사이의 구조적 불균형을 완화함으로써, 복잡한 위험환경 속에서도 일관된 책임귀속이 가능하도록 하는 이론적 기반을 마련하고자 한다.

2) 허황, 「인공지능과 형법상 행위론」, 『법학연구』 제25권 제3호 (2025), 131면.

3) Claus Roxin, Criminal Law: General Part, Vol. I (Oxford University Press, 2006), 11면.

II. 전통적 행위개념의 전개와 실행 중심 구조

1. 인과적 행위론의 자연주의적 전제

본 장에서는 전통적 행위개념이 어떠한 이론적 전개를 거쳐 형성되었는지를 검토하고, 그 공통적 특징이 실행행위를 중심으로 한 구조에 있음을 밝히고자 한다. 이를 위해 인과적 행위론, 목적적 행위론, 그리고 행위지배 이론과 객관적 귀속 이론의 전개를 순차적으로 검토하고, 이들 이론이 규범적 요소를 강화해 왔음에도 불구하고 행위개념 자체는 여전히 실행 중심으로 이해되는 경향이 있음을 확인한다. 이러한 검토는 이후 장에서 논의될 행위개념의 재정식화 필요성을 도출하기 위한 기초를 제공한다.

형법상 행위개념은 고전적 인과적 행위론에서 출발한다. 인과적 행위론은 행위를 “의사에 의해 지배되는 신체운동”으로 한정함으로써, 행위개념을 자연적 인과과정의 일부로 이해하였다⁴⁾. 행위는 범죄성립의 전제이지만, 그 자체는 규범적 의미를 지니지 않는 사실적 사건으로 이해된다. 구성요건 해당성은 결과와 행위 사이의 인과적 연결을 확인하는 단계에서 문제되고, 책임은 그 이후에 검토된다.

이러한 구조는 행위요건을 형사책임의 “최소한의 조건”으로 이해하는 전통과도 맞닿아 있다. Fletcher가 “The requirement of a voluntary act is the minimal condition of criminal liability”라고 지적하듯⁵⁾, 행위는 책임귀속을 가능하게 하는 문턱으로 기능한다. 그러나 여기서의 voluntary act 역시 신체적 실행을 전제로 한다는 점에서, 행위개념은 여전히 물리적 움직임의 차원에서 이해된다.⁶⁾

인과관계론의 발전 또한 이러한 전제를 벗어나지 못한다. 조건설은 결과발생에 기여한 모든 조건을 포섭함으로써 사실적 인과관계를 확장하였고, 상당인과관계설은 이를 규범적으로 제한하려 하였다. 그러나 이 논의는 어디까지나 결과귀속의 범위를 조정하는 작업일 뿐, 행위개념 자체를 재정식화하는 것으로 이어지지는 않는다. 조병선이 환경형법의 맥락에서 강조하듯, 과학적

4) 권영법, 「형법상 행위론에 대한 비판적인 고찰」, 『저스티스』 통권 제138호 (2013), 233면 이하.

5) Fletcher, 앞의 책, 409면.

6) Fletcher, 앞의 책, 409면.

개연성과 법적 귀속은 구별되어야 하며, 인과관계의 입증은 곧바로 책임귀속을 의미하지 않는다⁷⁾. 이는 인과관계의 규범화가 행위단계의 구조를 재구성하는 것과는 구별되는 문제임을 보여준다.

결국 인과적 행위론은 행위를 인과적 연쇄의 출발점으로 이해하는 경향을 보이며, 위험형성이나 통제관계와 같은 구조적 요소는 주로 행위개념 외부에서 다루어지는 측면이 있다. 행위는 자연적 사실로서 전제되고, 규범적 평가는 그 이후 단계로 이연되는 구조를 취한다. 이와 같은 이해는 행위를 결과발생의 물리적 출발점으로 파악하는 데에 중심을 두며, 행위의 존재론적 지위를 ‘사건’의 차원에서 이해하는 경향을 보인다.

이러한 인과적 행위론의 한계는 행위를 단순한 자연적 사건으로 환원함으로써, 행위의 규범적 의미를 충분히 설명하지 못한다는 점에 있다. 이러한 문제의식은 행위를 의미지향적 구조로 파악하려는 목적적 행위론으로 이어진다.

2. 목적적 행위론과 의미구조의 규범화

자연주의적 전제에 대한 반성은 행위를 단순한 인과적 사건이 아니라 규범적 의미구조로 파악하려는 시도로 이어지며, 이러한 문제의식은 목적적 행위론에서 본격화된다. Welzel은 행위를 단순한 신체운동이 아니라 목적지향적 의미구조로 파악함으로써, 행위의 본질을 의사의 지향성과 결부시켰다⁸⁾. 행위는 목적실현을 위한 합리적 조종행위이며, 구성요건 해당성은 그 목적적 구조를 전제로 이해되어야 한다.

이러한 전환은 행위의 규범적 성격을 전면에 부각시켰다는 점에서 중요한 의의를 갖는다. 정영일이 지적하듯, 목적적 행위론은 행위를 자연적 인과사건이 아니라 의미지향적 구조로 재정립하려는 시도였다⁹⁾. 그러나 이러한 재정립에도 불구하고, 그 분석의 중심은 여전히 구체적 실행행위를 매개로 이해되는 경향이 있다. 즉, 목적적 행위론은 행위의 내적 구조를 규범화하였으나, 그 전제는 실행이라는 요소와 긴밀히 결합되어 있다.

이와 같은 한계는 행위이론 전반에 공통적으로 나타난다. 권영법 또한 인

7) 조병선, 「비교법적 관점에서 본 한국 환경형법의 인과관계와 행위자의 특징」, 한티키 국제학술대회 발표논문, 2013, 160면 이하.

8) Hans Welzel, 『Das deutsche Strafrecht』, 11판 (1969), S. 33 ff.

9) 정영일, 「목적적 행위론의 형법철학적 의미」, 『형사법학』 제22권 제2호(2010), 143면 이하.

과적·목적적·사회적 행위론을 비판적으로 검토하면서, 이들 이론이 상이한 이론적 전제를 갖고 있음에도 공통적으로 실행행위를 중심에 두고 있음을 지적한다¹⁰⁾. 특히 행위의 기본기능·결합기능·한계기능이라는 전통적 설명들은 행위개념의 구조적 의미를 충분히 해명하지 못한다¹¹⁾. 이는 행위가 범죄론 체계의 출발점으로 선언되어 왔음에도, 그 내부의 규범적 밀도가 충분히 확보되지 않았음을 의미한다.

결국 목적적 행위론은 자연주의를 극복하였다는 점에서 이론적 진전을 이루었지만, 실행 중심 구조를 근본적으로 해체하지는 못하였다. 행위는 의미지향적 구조로 이해되었음에도 불구하고 여전히 구체적 실행을 매개로 파악되며, 위험형성의 구조적 조건은 행위의 외부에 남는다. 이로써 행위는 ‘의미를 지닌 사건’으로는 재정립되었으나, ‘위험질서 속의 위치’로는 재정위되지 못하였다. 위험의 형성이나 통제관계는 여전히 행위 이후의 단계에서 문제되는 것으로 남는다.

3. 행위지배 이론과 객관적 귀속의 규범화

행위지배 이론은 정범과 공범을 구별하는 기준으로 실현과정에 대한 지배를 제시한다. Roxin은 정범을 “Tatherrschaft”를 가진 자로 이해함으로써, 구성요건 실현과정에 대한 지배를 행위의 핵심으로 제시하였다¹²⁾. 이는 행위를 단순한 신체운동이 아니라 지배관계의 관점에서 파악하려는 시도였다.

그러나 이러한 지배개념 역시 구체적 실행과정에 대한 통제를 전제로 구성된다는 점에서 일정한 한계를 보인다. 김성돈이 대법원의 간접정범 법리를 비판하면서 우월적 의사지배라는 기준을 제시한 것¹³⁾ 또한, 실행과정에 대한 지배의 정교화를 요구하는 작업에 속한다. 즉 지배는 규범화되었지만, 그 전제는 여전히 실행행위다.

이와 같은 흐름은 결과귀속 판단을 규범화하려는 객관적 귀속 이론으로 이어진다. 객관적 귀속 이론은 허용되지 않은 위험의 창출과 그 위험의 실현

10) 권영법, 앞의 논문, 240면 이하.

11) 권영법, 앞의 논문, 250면 이하.

12) Claus Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 8. Aufl., 2006, S. 25 ff.

13) 김성돈, 「간접정범에 관한 대법원 법리와 형법이론학의 과제」, 『형사법연구』 제35권 제3호, 2023, 15면 이하.

여부를 중심으로 결과귀속을 판단함으로써, 인과관계의 사실적 측면과 규범적 측면을 구별한다. 김성돈은 위험창출 요건이 구성요건적 행위 해석과 결부될 수 있음을 지적한다¹⁴⁾. 그러나 이러한 시도 역시 행위단계를 근본적으로 재구성하기보다는, 위험의 평가를 귀속단계에서 보다 정교화하는 방향으로 전개되는 경향이 있다. 이에 따라 행위는 실행의 존재를 확인하는 기능을 중심으로 이해되는 측면이 유지된다.

영미 형법이론에서도 상황은 유사하다. Husak은 “Criminal liability requires conduct that can be fairly attributed to the actor”라고 하여 책임귀속 가능성을 행위요건과 연결한다¹⁵⁾. 그러나 이 역시 행위자를 중심으로 한 개별적 행위의 존재를 전제로 한다는 점에서, 구조적 위험형성과 직접적으로 연결되지는 않는다.

결국 행위지배 이론과 객관적 귀속 이론은 규범적 요소를 강화하였음에도 불구하고, 행위개념 자체를 실행 중심 구조로부터 해방시키지는 못하였다. 행위개념은 여전히 실행행위를 중심으로 이해되며, 위험형성의 구조적 조건은 행위 이후의 단계에서 평가된다.

4. 소결: 실행 중심 구조의 지속

이상에서 살펴본 전통적 행위이론의 전개는 다음과 같이 정리될 수 있다. 인과적 행위론은 행위를 자연적 신체운동으로 파악하였고, 목적적 행위론은 이를 의미지향적 구조로 전환하였으며, 행위지배 이론과 객관적 귀속 이론은 규범적 요소를 점차 강화하는 방향으로 발전하였다. 그러나 이러한 이론적 전개에도 불구하고, 행위개념은 공통적으로 실행행위를 중심으로 이해되고 있다.

즉 위험의 형성, 통제관계의 설정, 구조적 조건의 관리는 주로 인과관계 또는 귀속 단계에서 다루어지고, 행위단계는 여전히 실행의 존재를 확인하는 기능에 머문다. 이로써 행위는 범죄론 체계의 출발점으로 선언되면서도, 그 내부는 실행 중심 구조에 묶여 있는 이중적 상태를 보인다.

14) 김성돈, 「객관적 귀속이론과 구성요건에 해당하는 ‘행위’의 실체요건」, 『형사법연구』 제34권 제3호(2022), 210면 이하.

15) Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law* (Oxford University Press, 2008), 98면.

이러한 구조는 복합적·다층적 위험형성이 문제되는 현대적 상황을 설명하는데 일정한 한계를 보인다. 특히 위험이 규범적으로 평가되는 순간에도, 행위는 여전히 실행이라는 협소한 틀에 고정되어 있다. 이로 인해 행위개념과 객관적 귀속 이론 사이에는 구조적 긴장이 발생한다. 이러한 긴장은 단순한 이론적 불일치를 넘어, 형사책임 귀속 기준의 정합성과 관련된 논점으로 이어질 가능성을 내포한다. 다만 이러한 논의는 기존 이론이 전면적으로 타당성을 상실하였음을 의미하는 것이 아니라, 특정한 위험형성 구조에 대한 설명 방식에 재검토의 필요성을 시사하는 것으로 이해될 수 있다.

다음 장에서는 이 긴장을 분석함으로써, 행위개념의 재정식화가 이론적으로 왜 요청되는지를 검토한다.

III. 행위개념과 객관적 귀속 이론 사이의 구조적 긴장

1. 위험창출 요건과 구성요건적 ‘행위’의 접점

객관적 귀속 이론은 결과귀속 판단을 규범화함으로써 전통적 인과관계론의 한계를 극복하려는 시도였다. 허용되지 않은 위험의 창출과 그 위험의 실현 여부를 중심으로 결과귀속을 판단하는 구조는, 인과관계를 단순한 자연적 연결로 이해하던 입장에서 벗어나 규범적 통제를 도입하였다¹⁶⁾. 그러나 위험창출 요건은 필연적으로 “누가, 무엇을 통해, 어떠한 위험을 형성하였는가”라는 질문을 수반한다. 위험의 형성은 추상적 결과의 차원에서 발생하는 것이 아니라, 일정한 행위구조 속에서 발생한다. 김성돈이 지적하듯, 위험창출은 구성요건적 행위의 해석과 불가분의 관계에 있다¹⁷⁾. 위험이 창출되었다고 말하기 위해서는 먼저 그 위험을 형성한 행위를 특정해야 하기 때문이다. 위험창출 개념은 이미 행위의 규범적 의미를 전제한다. 그럼에도 위험에 대한 평가는 귀속단계에 집중되고, 행위단계는 실행의 존재를 확인하는 기능에 머문다. 이는 위험의 규범화와 행위의 형식화가 병존하는 구조를 낳는다.

문제는 바로 이 지점에서 발생한다. 전통적 행위개념은 행위를 실행행위로

16) 김성돈, 앞의 논문, 205면 이하.

17) 김성돈(2022), 215면 이하.

한정한다. 따라서 위험창출이라는 규범적 개념은 행위단계에서 다루어지지 않고, 귀속단계에서 비로소 문제된다. 결과적으로 행위는 실행의 존재를 확인하는 기능에 머물고, 위험의 규범적 평가는 행위 이후 단계로 이월된다. 이러한 구조는 단순한 체계적 구분을 넘어, 행위개념과 위험개념 사이의 불일치를 초래한다. 위험이 행위의 규범적 의미를 구성한다면, 행위단계는 더 이상 단순한 실행의 확인에 머물 수 없다. 그럼에도 불구하고 행위개념은 여전히 실행 중심의 틀 안에 고정되어 있으며, 이로 인해 행위와 귀속 사이의 구조적 긴장이 발생한다.

2. 행위단계와 귀속단계의 이원화 문제

행위개념과 객관적 귀속 이론 사이의 긴장은 행위단계와 귀속단계의 이원화에서 가장 분명하게 드러난다. 행위는 구성요건 해당성의 전제로 설정되지만, 그 내용은 물리적 실행에 국한된다. 반면 위험의 규범적 평가는 결과귀속 단계에서 이루어진다. 이러한 구조는 이론적 일관성을 약화시킨다. 위험이 허용되지 않았는지 여부는 이미 행위의 성격과 밀접히 연결되어 있음에도, 그 판단은 행위단계에서 배제된다. 행위는 “있음”의 문제로, 귀속은 “평가”의 문제로 분리된다.

조병선이 환경형법의 맥락에서 지적한 바와 같이, 과학적 개연성과 법적 귀속은 구별되어야 한다¹⁸⁾. 그러나 그 구별이 곧 행위와 귀속의 구조적 분리를 정당화하는 것은 아니다. 오히려 위험형성이라는 개념이 도입되는 순간, 행위는 단순한 인과적 출발점이 아니라 규범적 의미를 지닌 구조로 재해석될 필요가 있다.

영미 형법이론에서도 행위요건은 책임귀속의 전제조건으로 이해된다. Fletcher는 행위를 “conduct that expresses the actor’s will”로 파악한다¹⁹⁾. 그러나 이러한 이해 역시 개별 행위자의 의사표현에 초점을 두며, 구조적 위험형성과 직접적으로 연결되지는 않는다. Husak 또한 책임귀속 가능성을 행위요건과 결부시키지만²⁰⁾, 그 전제는 여전히 개별적 행위의 존재다.

18) 조병선, 앞의 논문, 168면 이하.

19) Fletcher, 앞의 책, 413면.

20) Husak, 앞의 책, 98면.

결국 행위단계와 귀속단계의 분리는 이론적 편의를 제공하지만, 위험형성의 구조적 성격을 충분히 설명하지 못한다. 행위는 실행의 확인으로 축소되고, 위험은 사후적 평가의 대상으로 처리된다. 이 분리는 형식적으로는 단계적 범죄론 체계를 유지하지만, 실질적으로는 행위개념의 규범적 밀도를 약화시킨다. 특히 위험이 행위의 의미를 구성하는 요소로 기능함에도 불구하고, 행위는 여전히 실행이라는 협소한 틀에 머물러 있다는 점에서, 기존 체계는 구조적 긴장을 내포한다.

3. 행위개념의 구조적 공백

위험창출 요건이 구성요건적 행위 해석과 밀접하게 연결될 수 있음에도, 행위개념은 여전히 실행 중심 구조에 머문다. 이 문제는 행위개념이 위험형성의 구조적 자원을 충분히 포섭하지 못한다는 데에서 발생한다. 이는 행위개념이 역사적으로 “신체운동”을 중심으로 형성되어 왔기 때문이다. 자연주의를 극복한 목적적 행위론과 행위지배 이론 역시 실행을 매개로 한 지배를 전제한다. 그 결과 위험형성의 구조적 차원은 행위단계에 충분히 통합되지 못한다. 위험은 결과귀속 단계에서 규범적으로 평가되지만, 그 위험을 가능하게 한 구조적 조건은 행위개념 내부에 반영되지 않는다. 이로써 행위개념은 형식적 전제로 남고, 규범적 판단의 실질은 귀속단계에 집중된다.

이러한 구조는 복잡한 기술작조직적 환경에서 특히 한계를 드러낸다. 위험은 단일한 실행행위에서 발생하기보다, 설계·운영·관리 등 복수의 단계에서 형성된다. 그럼에도 행위개념이 실행 중심으로 유지될 경우, 위험형성의 구조적 차원은 이론적으로 충분히 포섭되지 못한다.

이와 같은 행위단계와 귀속단계의 이원화는 단순한 체계상의 구분을 넘어, 형사책임 귀속의 실질적 기준 형성에 영향을 미친다. 행위단계가 실행행위의 존재를 확인하는 기능에 머무르는 경우, 위험형성에 실질적으로 기여한 다양한 조건들은 행위개념 내부에서 포착되지 못하고, 그 평가가 귀속단계로 이월된다. 그 결과 귀속단계는 허용되지 않은 위험의 창출 여부뿐만 아니라, 책임 주체의 특성과 그 범위 설정까지 포괄하는 과도한 기능을 수행하게 된다. 이러한 구조는 위험형성 과정이 복잡하고 다층적으로 이루어지는 현대 사회에서 특히 문제를 발생시킨다. 위험형성에 중요한 영향을 미친 행위주체가

행위단계에서 배제되거나, 반대로 제한된 관여를 한 행위자에게 과도한 책임이 귀속될 가능성이 존재하기 때문이다. 결국 행위개념이 구조적 위험형성을 충분히 포섭하지 못하는 한, 형사책임의 귀속 기준은 불명확해지고, 체계 내부의 기능적 균형 또한 약화될 수밖에 없다.

결국 행위개념과 객관적 귀속 이론은 상호 보완적 관계에 있으면서도, 구조적으로는 긴장을 내포한다. 위험이 규범적으로 평가되는 순간에도, 행위는 여전히 협소한 실행개념에 묶여 있기 때문이다. 즉, 위험형성이 구조의 문제로 전환되는 상황에서 행위개념이 이를 내부화하지 못하는 한, 행위단계는 필연적으로 구조적 공백을 남기게 된다.

IV. 위험구조에 대한 규범적 통제로서의 행위

1. 행위개념의 재위치와 체계적 요청

전통적 행위개념이 실행 중심 구조에 머무르고 있다는 점을 고려할 때, 행위개념은 위험형성의 구조적 차원을 반영하는 방향으로 재위치될 필요가 있다. 전통적 행위개념은 인과적·목적적·지배이론적 전개를 거치면서 점차 규범적 요소를 수용하여 왔다. 그럼에도 불구하고 그 구조적 중심은 실행행위에 머물러 있었다. Welzel은 행위를 목적지향적 의미구조로 이해함으로써 자연주의를 극복하고자 하였으나, 그 목적은 여전히 구체적 실행을 매개로 이해되었다²¹⁾. Roxin 역시 정범을 구성요건 실현과정을 지배하는 자(Tatherrschaft)로 파악함으로써 정범성의 근거를 행위지배 개념에 두었으나, 그 지배는 실행과정에 대한 통제를 전제로 구성된다²²⁾. 이와 같은 이해는 행위를 결과발생의 물리적 출발점으로 고정함으로써, 행위의 존재론적 지위를 ‘사건’의 차원에 한정한다. 위험이 규범적으로 구성되는 한, 행위는 더 이상 단순한 인과적 계기로 환원될 수 없다.

객관적 귀속 이론은 허용되지 않은 위험의 창출을 중심으로 결과귀속 판단을 규범화하였다²³⁾. 그러나 위험창출 요건이 도입된 이후에도 행위개념은

21) Welzel, 앞의 책, S. 39 ff.

22) Claus Roxin, 앞의 책, § 11 Rn. 39-45.

실행 중심의 구조를 유지하였다. 김성돈이 지적하듯, 위험창출 요건은 구성요건적 행위 해석과 불가분의 관계에 있음에도, 실제 이론 전개에서는 귀속단계에서 논의되는 경향이 강하다²³⁾. 이로써 위험은 규범적 구조로 이해되면서도, 행위는 여전히 실행이라는 사실적 계기에 고정된다.

행위단계와 귀속단계의 이원화는 단순한 분석상의 구별에 그치지 않는다. 범죄론 체계에서 행위단계는 책임 귀속의 출발점으로서 규범적 판단의 기초를 제공하는 기능을 수행한다. 그럼에도 불구하고 행위개념이 실행이라는 사실적 계기에 머무르는 경우, 행위단계는 실질적 판단을 담지하지 못한 채 형식적 전제로 전락하게 된다.

그 결과 위험의 창출, 규범적 위반, 책임의 귀속에 관한 판단은 귀속단계에 과도하게 집중되며, 단계적 구조가 전제하는 기능적 분화는 약화된다. 이러한 구조는 행위단계와 귀속단계 사이의 논리적 선행관계를 흐리게 하고, 범죄론 체계 전체의 정합성을 훼손한다. 따라서 행위개념이 위험형성의 구조를 반영하지 못하는 상태에서 유지되는 이원화는 단순한 이론적 구성이 아니라, 체계적 결함으로 평가될 수 있다.

행위단계가 체계의 출발점이라면, 위험형성의 구조적 차원은 그 내부에 통합되어야 한다. 그렇지 않은 경우 행위는 형식적 전제로 남고, 규범적 판단은 귀속단계에 집중된다. 이러한 불균형은 단계적 범죄론 체계가 전제하는 기능적 분담을 붕괴시키며, 체계 전체의 정합성을 근본적으로 훼손한다.

2. 위험형성 질서와 행위의 구조적 위치

이러한 문제의식을 전제로 할 때, 행위는 더 이상 신체운동이라는 물리적 계기로 환원될 수 없다. 목적적 행위론이 행위를 의미구조로 이해한 이후, 행위는 의사와 목적을 포함하는 의미구조로 파악되어 왔다. 그러나 그 분석은 여전히 실행을 매개로 한 결과 실현을 전제한다는 점에서, 행위를 사건의 차원에 머물게 한다.

위험형성의 관점에서 보면, 행위의 본질은 특정한 결과를 초래할 수 있는 조건을 단순히 발생시키는 데 있지 않다. 문제는 그러한 조건들이 어떠한 질

23) Claus Roxin, Zur objektiven Zurechnung, 74 ZStW (1962).

24) 김성돈(2022), 앞의 논문, 205-215면.

서 속에서 배치되는가에 있다. 위험은 단일한 신체운동에서 발생하는 것이 아니라, 일정한 구조 속에서 형성된다. 이러한 구조적 위험형성은 특히 환경 범죄 영역에서 분명하게 드러난다. 조병선이 과학적 개연성과 법적 귀속을 구별하면서 인과관계의 입증은 곧바로 책임귀속을 의미하지 않는다고 지적한 점은, 결과 발생의 조건과 위험형성 질서의 문제를 구별해야 함을 보여준다²⁵⁾.

인과관계론이 결과발생에 기여한 조건을 설명하는 작업이라면, 위험형성 질서의 문제는 결과 발생 가능성이 어떠한 구조 속에서 배치되어 있는가에 관한 것이다. 이때 행위는 단순한 인과적 계기가 아니라, 위험형성 질서 속에서 일정한 위치를 점유하는 것으로 이해된다. 권영법이 통합적 행위론을 제안하면서 행위를 체계적 기능을 수행하는 구조로 파악한 점은, 행위를 사건이 아니라 체계 내부의 자리로 이해할 가능성을 시사한다²⁶⁾.

따라서 행위는 더 이상 규범적 평가의 대상이기 이전에, 위험형성 질서 내부에서 결과 가능성을 구조적으로 배치하는 존재론적 위치로 이해되어야 한다. 실행은 그 구조가 외부로 드러나는 계기에 불과하며, 행위의 본질은 그 이전 단계의 구조적 배치에 있다. 이러한 이해는 기존 이론을 단순히 수용하는 데 그치지 않고, 실행 중심 행위개념이 전제하고 있는 구조적 한계를 재검토하여 이를 재구성하려는 시도에 해당한다.

3. 행위와 귀속의 구조적 재정렬

행위를 위험형성 질서 속의 구조적 위치로 이해할 경우, 행위단계와 객관적 귀속 이론 사이의 관계는 단순한 단계적 분리를 넘어 구조적으로 재정렬될 필요가 있다. 전통적 범죄론 체계에서 행위단계는 주로 실행행위의 존재를 확인하는 기능에 머무르는 반면, 위험의 규범적 평가는 객관적 귀속 단계에서 이루어진다. 이러한 구조에서는 위험형성에 실질적으로 기여한 다양한 행위요소들이 행위단계에서 충분히 포착되지 못하고, 그 평가가 귀속단계로 이월되는 경향이 나타난다. 그 결과 귀속단계는 위험의 창출 여부뿐만 아니라 행위자의 특징과 책임범위의 설정까지 담당하게 되어 기능적 부담이 과도

25) 조병선, 앞의 논문, 168면 이하.

26) 권영법, 앞의 논문, 240-250면.

하게 집중된다.

이러한 문제는 위험이 단순한 결과의 속성이 아니라 일정한 행위구조 속에서 형성된다는 점에서 더욱 분명해진다. 객관적 귀속 이론이 위험창출을 결과귀속 판단의 핵심 기준으로 설정하고 있음에도 불구하고, 행위개념이 여전히 실행 중심으로 이해되는 한, 위험형성과 행위 사이의 규범적 연결은 체계 내부에서 충분히 정합적으로 설명되기 어렵다. 위험창출 여부를 판단하는 순간, 이미 특정한 행위구조와 그 안에서의 위치가 전제되기 때문이다.

따라서 재정렬의 핵심은 행위를 단순한 실행의 존재로 파악하는 것이 아니라, 위험형성 구조 속에서 행위자가 점유하는 위치로 이해하는 데 있다. 이러한 재정렬은 단계적 범죄론 체계를 해체하는 것이 아니라, 오히려 각 단계의 기능을 명확히 분화하는 작업에 해당한다. 즉, 행위단계는 위험형성 질서 속에서 행위자가 어떠한 통제 지위를 점유하고 있었는지를 확인하는 단계로 기능하고, 귀속단계는 그 위험이 구체적 결과로 실현되었는지를 판단하는 단계로 한정되며, 책임단계는 그러한 통제 가능성과 비난가능성을 중심으로 책임의 정당화를 검토하는 단계로 이해된다.

이러한 기능적 재배치는 행위단계의 형식화와 귀속단계의 비대화라는 기존 구조의 문제를 완화하고, 각 단계의 역할을 보다 명확히 함으로써 범죄론 체계의 정합성을 강화하는 효과를 갖는다. Husak이 형사책임을 행위자의 통제 가능성과 도덕적 지위에 기초한다고 본 점 역시, 책임 판단의 핵심이 단순한 결과 발생이 아니라 통제 가능성에 있음을 시사하며, 이는 행위단계를 구조적 통제 지위의 관점에서 재이해할 필요성을 뒷받침한다.²⁷⁾

이러한 이해는 행위개념의 외연을 확장하는 것이 아니라, 위험이 이미 규범화된 구조로 이해되는 상황에서 행위의 존재론적 지위를 그에 상응하도록 정렬하는 작업에 해당한다. 실행은 위험형성 질서가 외부로 드러나는 계기에 불과하며, 행위의 본질은 그 구조적 위치에서 파악되어야 한다.

4. 현대적 위험환경에서의 이론적 적합성

이와 같이 행위를 위험형성 구조 속의 위치로 재이해할 경우, 이러한 관점

27) Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2008), 75-83면.

은 현대적 위험환경에서 더욱 분명한 설명력을 갖는다. 이러한 설명은 단순히 새로운 상황에 대한 보충적 해석이 아니라, 앞서 살펴본 바와 같이 전통적 행위 개념이 실행 중심 구조에 머무름으로써 위험형성의 구조적 차원을 포착하지 못한다는 한계를 전제로 한다.

복잡한 조직적·기술적 환경에서는 위험이 단일한 실행행위에서 발생하지 않는다. 위험은 설계, 학습, 운영, 감독이라는 복합적 과정 속에서 점진적으로 형성되며, 그 형성은 다층적 구조를 통해 매개된다. 인공지능 시스템이 의사결정 과정에 깊이 개입하는 상황은 이러한 구조적 위험형성을 극명하게 드러낸다. 허황은 인공지능 환경에서 전통적 행위개념이 충분한 설명력을 갖지 못함을 지적하면서, 행위와 책임의 연결구조를 재검토할 필요성을 제기한다²⁸⁾.

실행 중심의 행위개념은 이러한 위험구조를 충분히 포착하지 못한다. 실행은 이미 형성된 구조가 외부로 드러나는 계기에 불과할 수 있으며, 위험의 방향과 강도는 그 이전 단계에서 사실상 규정된다. 특히 자율적 시스템이 작동하는 상황에서는 결과 발생이 인간의 직접적 신체운동과 단절된 형태로 나타나기도 한다. 이 경우 실행은 책임 판단의 실질적 기준이 되기 어렵다. 중요한 것은 누가 실행을 수행하였는가가 아니라, 누가 위험구조의 형성과 유지에 실질적으로 관여하였는가라는 점이다. 위험은 자연적 사건이 아니라 구조적 조건 속에서 발생하며, 그 조건을 설정하거나 지속시킬 수 있는 위치는 형사법적으로 무의미하지 않다. 이러한 관여는 단순한 조건적 기여와 구별된다. 그것은 위험의 발생 가능성을 방향짓는 구조적 지위에 관한 문제이다.

이와 같이 각 단계에서 드러난 문제는 서로 독립된 한계라기보다, 행위를 실행의 계기로 한정함으로써 위험이 형성되는 구조 전체를 포착하지 못한다는 점에서 공통된 방향으로 수렴한다. 따라서 행위를 위험구조에 대한 통제가능성의 관점에서 이해하는 것은 기술적 특수성에 대한 임시적 대응이 아니다. 그것은 이미 위험이 규범적으로 평가되고 있는 형법 체계 내부의 비대칭을 정리하는 작업이다. 위험이 구조적 상태로 이해되는 이상, 행위 또한 그와 상응하는 구조적 차원에서 파악되어야 한다. 그렇지 않으면 행위는 형식적 전제로 축소되고, 책임 판단의 실질은 귀속단계에 과도하게 집중될 수밖에 없다. 이러한 재정위는 행위개념의 확장이 아니라, 형법 체계 내부의 구조적

28) 허황, 앞의 논문, 127-152면.

균형을 회복하려는 시도에 해당한다. 실행은 더 이상 행위의 본질이 아니라, 위험구조가 현실화되는 한 계기일 뿐이다. 따라서 행위개념은 더 이상 결과 발생의 출발점을 특정하는 기능에 머무르지 않고, 위험형성 구조 속에서 행위자가 점유하는 통제가능성의 범위를 드러내는 기준으로 재검토될 필요가 있다.

이하에서는 이러한 문제의식을 전제로 전통적 행위개념의 구조적 한계를 검토하고, 인공지능 환경에서 그 한계가 어떻게 드러나는지를 통해 책임귀속 기준의 재정립 가능성을 구체화한다.

V. 인공지능 환경에서 드러난 체계적 긴장과 행위개념 재정위의 필연성

1. 기술적 매개와 위험형성의 구조화

복잡한 조직적·기술적 환경에서는 위험이 단일한 실행행위로 환원되기보다, 그 발생가능성을 형성하거나 유지하는 다양한 조건들에 대한 통제관계 속에서 형성된다. 이러한 점에서 인공지능 환경은 위험형성이 단일 행위의 문제가 아니라 구조의 문제로 전환되고 있음을 보여준다. 특히 인공지능 시스템은 결과 산출 과정의 구조적 요소로 통합되며, 특정 결정이 인간의 직접적 신체운동과 무관하게 결과로 이어질 수 있다. 이러한 기술적 매개는 위험형성이 기존의 실행 중심 틀로 충분히 포착되기 어려운 보다 복합적인 양상을 보임을 시사한다. 허황은 인공지능 환경에서 행위개념이 더 이상 실행의 물리적 계기에만 근거할 수 없으며, 기술적 매개가 위험형성 구조 자체를 변화시키고 있음을 지적한다.²⁹⁾ 이러한 논의는 인공지능의 책임능력 여부를 직접 문제 삼기보다, 행위 개념이 전제하고 있는 실행 중심 구조 자체를 재검토할 필요성을 시사한다. 특히 인공지능 시스템은 행위의 실행 시점이 아니라 설계·운영·감독의 구조 속에서 위험이 형성된다는 점에서, 실행행위를 중심으로 한 전통적 책임 귀속 구조의 한계를 가장 선명하게 드러낸다.

다만 이러한 위험형성의 구조는 인공지능에 특유한 현상으로만 이해될 수

29) 허황, 앞의 논문, 131면 이하.

는 없다. 위험이 단일한 신체운동이 아니라 설계·데이터 구성·운영정책·감독 체계 등 다층적 조건 속에서 형성된다는 점은, 위험사회론에서 지적되어 온 바와 같이 현대 과학기술 전반에 걸쳐 나타나는 구조적 특징이다. 그럼에도 불구하고 인공지능 환경은 이러한 구조적 위험형성을 가장 집약적이고 가시적인 형태로 드러낸다는 점에서, 실행 중심 행위개념의 한계를 분석하는 데 있어 특별한 의미를 갖는다. 인공지능은 새로운 유형의 위험을 창출한다기보다, 이미 존재해 온 구조적 위험형성의 문제를 보다 극단적이고 명확한 형태로 드러내는 계기로 기능한다.

이런 상황에서 전통적 행위개념은 위험형성의 구조적 차원을 설명하는 데 일정한 한계를 보일 수 있다. 실행은 그 구조가 외부로 드러나는 계기에 불과하며, 위험의 방향과 강도는 그 이전 단계에서 이미 사실상 설정되는 경우가 많다. 결과의 발생이 인간의 직접적 신체운동 없이 이루어질 수 있을 때, 실행 중심의 행위개념은 위험형성의 핵심 구조를 충분히 포착하기 어려운 측면이 있다. 문제는 누가 실행을 수행하였는가가 아니라, 누가 위험구조의 형성과 유지에 실질적으로 관여하였는가에 있다. 이러한 문제의식은 전통적 행위개념의 구조적 한계를 드러내는 데 그치지 않고, 위험형성 구조를 실질적으로 통제할 수 있었던 행위자를 중심으로 책임 귀속 판단 기준을 재구성할 필요성을 제기한다.

2. 실행 중심 행위개념의 한계와 행위자 특성의 문제

실행 중심 행위개념은 전통적으로 행위자 특성의 기준을 제공해 왔다. 행위자는 구성요건적 실행을 수행한 자로 특정되며, 이후 단계에서 위험의 허용 여부와 결과귀속이 평가된다. 이러한 구조에서는 실행이 행위자 특성의 1차적 표지로 기능한다.

그러나 결과가 인간의 직접적 신체운동을 매개로 하지 않는 경우, 행위자 특성은 더 이상 실행만을 중심으로 정리되기 어려운 측면이 나타난다. 위험은 실행 이전의 구조적 조건 속에서 형성되며, 실행은 그 구조가 외부로 드러나는 계기에 불과할 수 있다. 그 결과 행위단계에서 해결되지 못한 특성의 문제는 귀속단계로 이월된다. 귀속단계는 허용되지 않은 위험의 창출 여부를 판단하는 기능을 넘어, 누가 그 위험구조의 중심에 위치하는지까지 판단해야

하는 부담을 지게 된다. 이는 귀속단계의 기능적 비대화를 초래한다³⁰⁾.

이러한 구조는 행위단계가 담당하여야 할 행위자 특정과 위험형성의 기초적 판단 기능이 귀속단계로 이전되는 결과를 초래하며, 단계적 범죄론 체계가 전제하는 기능적 분담을 약화시킨다. 이는 단순한 설명상의 문제를 넘어, 체계 내부에서 각 단계가 수행하여야 할 역할이 불명확해진다는 점에서 논리적 정합성의 문제로 이어진다.

이 점은 Husak이 형사책임의 귀속 가능성을 행위자의 행위 및 통제와 연결하여 설명하는 문제의식과도 맞닿아 있다.³¹⁾ Husak은 형사책임이 단순한 결과 발생이 아니라 행위자의 통제 가능성과 도덕적 지위에 의해 정당화된다고 보며³²⁾, 이는 책임 귀속의 기준이 물리적 실행이 아니라 통제 가능성에 있음을 시사한다. 이러한 관점은 본 논문이 제시하는 구조적 통제 중심의 책임 재구성예 이론적 근거를 제공한다.

동시에 책임정당화의 근거 역시 불안정해진다. 형사책임은 결과의 물리적 직접성에 기초하지 않는다. 그것은 특정 행위자에게 결과를 정당하게 귀속시킬 수 있는가에 대한 판단이다. 이 판단은 결과를 초래한 위험을 행위자가 통제할 수 있었는지에 대한 평가를 포함한다. 허황이 지적하듯, 인공지능 환경에서는 위험형성이 구조적으로 이루어지기 때문에 통제 가능성 역시 단순히 실행 순간에 국한하여 파악할 수 없다³³⁾. 이러한 점은 책임정당화의 기준이 실행행위의 존재가 아니라 위험형성에 대한 통제 가능성에 있다는 점을 전제할 때, 그 판단의 기초가 되는 행위단계 역시 이에 상응하는 방식으로 재구성될 필요가 있음을 의미한다.

그러나 위험형성이 구조적으로 이루어지는 상황에서는 통제 가능성이 실행 순간에 한정되지 않는다. 위험은 설계·조직·운영·감독이라는 다층적 조건 속에서 형성되며, 그 구조를 사실상 결정하는 위치가 존재할 수 있다. 실행 중심 이해는 책임의 근거를 물리적 계기에 결부시키는 경향을 강화하지만, 구조적 위험형성 환경에서는 그러한 연결은 설명력이 제한될 수 있다. 이 점에서 책임정당화의 구조는 재검토가 요구된다.

30) Husak, 앞의 책, 96-103면.

31) Husak, 앞의 책, 96-103면.

32) Husak, 앞의 책, 90-103면.

33) 허황, 앞의 논문, 18-27면.

이와 같은 구조적 한계는 인공지능 환경에서 더욱 선명하게 드러난다. 인공지능 시스템에서는 결과 발생이 인간의 직접적 실행과 분리되는 경우가 많으며, 그 과정에서 위험형성은 설계·데이터 구성·운영·감독 등 다양한 단계에 걸쳐 분산된다. 이러한 상황에서는 단순히 실행행위를 수행한 주체를 기준으로 책임을 귀속시키는 접근의 설명력이 제한될 수 있으며, 위험형성 구조에 대한 관여 양상을 중심으로 책임 귀속의 문제를 재검토할 필요성이 제기된다.

따라서 문제는 단순히 귀속단계의 판단 기준을 정교화하는 데에 있지 않다. 오히려 행위개념이 위험형성의 구조적 차원을 반영하지 못하는 한, 책임 귀속의 기준 역시 체계 내부에서 일관되게 작동하기 어렵다. 이는 행위단계와 귀속단계의 관계를 재정렬할 필요성을 제기하며, 행위개념을 구조적 통제와 관점에서 재정식화할 것을 요구한다.

인공지능 관련 형사책임 논의가 반복적으로 드러내는 난점 역시 이와 무관하지 않다. 결국 문제는 인공지능의 형사책임 주체성 여부가 아니라, 위험형성 구조를 사실상 결정하거나 유지할 수 있었던 행위자를 중심으로 책임을 귀속시킬 수 있는가에 있다³⁴⁾. 실행 중심 행위개념이 유지되는 한, 이러한 문제는 체계 내부에서 충분히 해명하기 어려운 측면이 존재한다. 이러한 문제는 단순히 귀속단계의 판단 기준을 정교화하는 것으로 해결될 수 있는 것이 아니라, 위험형성 구조에 대한 통제 가능성을 중심으로 책임귀속의 기준을 재정립할 필요성을 시사한다.

3. 책임정당화의 기준과 통제 가능성의 위치

형사책임은 결과 발생에 대한 사실적 반응이 아니라, 특정 행위자에게 결과를 정당하게 귀속시킬 수 있는지에 대한 규범적 판단이다. 범죄론 체계에서 행위가 책임의 전제조건으로 이해되어 온 이유도 여기에 있다. 그러나 책임정당화의 실질적 기준이 범죄론 체계의 어느 단계에서 어떠한 방식으로 작동하는지에 관하여는 일관된 이론적 정리가 이루어졌다고 보기 어렵다.

Fletcher는 자발적 행위요건(voluntary act requirement)을 형사책임의

34) 박광민·백민제, 「인공지능 로봇의 범죄주체성과 형사책임의 귀속」, 『인하대학교 법학연구』 제20집 제4호(2017), 164-170면.

최소 조건으로 이해하면서도, 행위를 단순한 신체운동으로 환원할 수 없다고 지적한다³⁵⁾. 이는 행위 개념이 단순한 물리적 사건이 아니라 규범적 의미를 지닌 개념임을 전제로 하며, 행위를 신체운동과 동일시하는 실행 중심 이해에 한계를 드러낸다. 자발성은 물리적 움직임이 아니라 의지의 표현이라는 점에서, 행위는 이미 규범적 의미를 내포한다. Husak 역시 형사책임은 단순한 결과발생이 아니라 행위자의 통제 가능성과 도덕적 지위에 기초하여 정당화된다고 본다³⁶⁾. 이러한 논의는 책임의 핵심이 결과 그 자체에 있지 않고, 행위자가 결과를 야기한 위험을 통제할 수 있었는지에 있다는 점을 시사한다.

이러한 통제 가능성은 단순한 책임 판단의 보조 기준이 아니라, 행위와 위험, 귀속을 연결하는 구조적 매개로 이해될 필요가 있다. 만약 통제 가능성이 귀속 단계에서만 고려된다면, 행위 단계는 여전히 사실적 전제에 머무르게 된다. 반대로 통제 가능성을 행위 단계의 구성 요소로 이해할 경우, 행위는 위험형성 구조 속에서의 통제 지위를 평가하는 개념으로 재정립될 수 있다.

문제는 통제 가능성의 위치이다. 전통적 실행 중심 행위개념에서는 통제 가능성이 실행의 순간에 집중된다. 그러나 현대의 위험은 실행의 순간에 비로소 발생하는 것이 아니라, 그 이전 단계에서 형성된다. 설계의 선택, 데이터 구조의 구성, 운영정책의 설정, 감독체계의 유지 등은 결과의 방향과 강도를 결정한다. 이러한 요소들은 이전 단계에서 이미 위험의 형성을 규정한다. 따라서 실행은 이미 형성된 구조가 외부로 드러나는 계기에 불과할 수 있다.

그렇다면 책임정당화의 기준 역시 실행의 물리적 직접성뿐만 아니라, 위험형성 구조에 대한 통제 지위에서 찾아야 한다. 행위개념이 이러한 구조적 통제 가능성을 반영하지 못한다면, 책임의 철학적 근거는 체계 내부에서 분리된다. 위험은 객관적 귀속 단계에서 규범적으로 정교화되었으나, 행위 단계의 규범적 기능은 이에 상응하여 충분히 재구성되지 못하였다. 이 긴장은 인공지능 환경에서 더욱 선명하게 드러난다.

이와 같은 ‘실제적 통제’는 단순한 추상적 개념에 그치는 것이 아니라, 구체적 책임귀속 판단에서 다음과 같은 구조적 기준으로 이해되어야 한다. 즉,

35) Fletcher, 앞의 책, 415-418면; 이인곤강철하, 「인공지능 로봇의 형사법이론 체계에 관한 일고」, 『법학연구』 제18권 제3호(2018), 22면 이하.

36) Husak, 앞의 책, 90-103면.

통제 가능성은 (1) 위협의 발생을 사전에 인식할 수 있었는지 여부라는 점에서의 예측 가능성, (2) 위협형성과정에 개입하거나 이를 수정할 수 있는 구조적 위치에 있었는지 여부라는 점에서의 개입 가능성, (3) 그러한 통제 실패를 해당 행위자에게 규범적으로 귀속시키는 것이 정당화되는지 여부라는 점에서의 책임 귀속 가능성이라는 세 가지 요소를 중심으로 판단되어야 한다.

앞서 제시한 설계 관여, 통제 수단의 보유, 위협 인식 가능성, 영향력의 범위 등은 이러한 판단 기준을 구체화하는 하위 요소로 기능한다.

따라서 통제 가능성에 기초한 책임귀속은 단순한 요소의 존재 여부가 아니라, 해당 행위자가 위협형성의 방향과 결과에 대하여 실질적 결정력을 행사할 수 있었는지를 기준으로 판단되어야 한다. 특히 (i) 위협구조의 핵심 설계에 관여하였거나, (ii) 그 구조를 수정·중단할 수 있는 권한을 보유하고 있었으며, (iii) 위협의 발생을 예견하고 개입할 수 있었음에도 이를 방치한 경우에는, 실질적 통제 가능성이 인정되어 형사책임의 귀속이 정당화될 수 있다.

이러한 기준에 비추어 보면, 통제 가능성에 대한 판단은 단일 요소의 충족 여부에 따라 기계적으로 결정되는 것이 아니라, 위협형성 구조에 대한 관여의 방식과 정도를 종합적으로 고려하여 이루어져야 한다. 즉, 설계 관여, 통제 수단의 보유, 위협 인식 가능성, 영향력의 범위 등 개별 요소들은 독립적인 기준이라기보다 상호 결합된 판단 요소로 기능하며, 특정 행위자가 위협형성의 방향과 전개에 대하여 실질적인 결정력을 행사하였는지가 핵심적인 판단 기준이 된다. 이러한 종합적 판단 구조는 기존 형법이론에서 다양한 요소를 종합하여 책임 여부를 판단해 온 방식과도 정합적이며, 통제 가능성 기준이 새로운 판단 체계를 도입하는 것이 아니라 기존 판단 구조를 구조적 위험환경에 맞게 재정렬하는 것임을 보여준다.

이러한 기준에 따르면, 모든 영향력을 가진 행위자가 책임을 부담하는 것은 아니다. 책임귀속은 단순한 영향력의 존재가 아니라, 위협형성 구조에 대한 실질적 통제 가능성이 인정되는 범위로 한정되어야 한다. 이는 책임의 범위를 무한히 확장하는 것을 방지하기 위한 기능적 요청이기도 하다. 만약 영향력만으로 책임을 인정할 경우, 위협형성 과정에 간접적으로 관여한 다수의 행위자들이 모두 책임의 주체로 포섭될 위험이 있으며, 이는 형사책임의 개인책임 원칙과도 긴장을 초래할 수 있다. 따라서 책임귀속은 결과에 대한 단

순한 인과적 기여가 아니라, 위험형성의 방향과 전개에 대하여 실질적으로 개입할 수 있었는지 여부를 중심으로 제한적으로 설정될 필요가 있다.

이와 관련하여 영향력과 지배는 구별될 필요가 있다. 영향력은 결과 형성에 기여하는 다양한 요소를 포함할 수 있는 반면, 지배는 위험형성 구조의 방향과 강도를 실질적으로 결정할 수 있는 통제력을 의미한다. 영향력은 정도의 차이를 가지며 광범위하게 분포될 수 있는 반면, 지배는 특정한 위치에서 구조 전체의 작동에 결정적 영향을 미칠 수 있는 통제력을 전제로 한다는 점에서 질적으로 구별된다. 따라서 책임귀속의 기준은 단순한 영향력의 존재가 아니라, 구조적 지배의 정도에 따라 설정될 필요가 있다. 이러한 구별은 위험형성 과정에 다수의 행위자가 관여하는 경우에도, 책임의 중심을 특정한 통제 지위에 집중시킴으로써 책임 귀속의 범위를 합리적으로 한정하는 기능을 수행한다.

또한 이러한 통제 가능성 기준은 과실 판단과도 밀접하게 연결된다. 즉, 위험을 예견할 수 있었는지 여부와 이를 회피하거나 수정할 수 있는 통제수단을 보유하고 있었는지는 과실 책임의 핵심 요소를 구성한다. 특히 과실범에서 요구되는 주의의무는 추상적 행위규범이 아니라, 행위자가 구체적 상황에서 어떠한 통제수단을 보유하고 있었는지를 전제로 평가되어야 한다는 점에서, 통제 가능성은 주의의무의 내용과 범위를 구체화하는 기준으로 기능할 수 있다. 이러한 점에서 통제 가능성은 행위단계의 개념에 그치지 않고, 과실범의 주의의무 판단 기준으로도 기능할 수 있다. 나아가 이는 결과 발생 이후의 사후적 평가가 아니라, 위험형성 단계에서 요구되는 사전적 통제의무를 규범적으로 정당화하는 근거로도 작용할 수 있다.

이와 같이 통제 가능성은 단순히 책임단계의 평가 기준에 그치는 것이 아니라, 행위단계에서부터 위험형성에 대한 통제 가능성을 포섭함으로써 범죄론 체계 전체의 구조적 정합성을 확보하는 기준으로 기능한다. 이는 통제 가능성을 행위개념과의 관계 속에서 재검토할 필요성을 제기하며, 행위단계와 책임단계 사이의 단절을 구조적으로 해소할 수 있는 가능성을 드러낸다. 이러한 기준은 자율적 시스템이 개입된 구체적 상황에서도 책임귀속 판단의 기준으로 적용될 수 있다. 또한 통제 가능성의 분포에 따라 책임의 귀속 범위와 정도를 정교하게 설정할 수 있는 이론적 틀을 제공한다.

이러한 기준은 자율적 시스템이 개입된 구체적 상황에서도 다음과 같이 적

용될 수 있다.

예컨대, 인공지능 기반 환경영향평가 시스템이 특정 개발사업의 환경 위험을 과소평가하여 허가가 이루어진 경우를 상정할 수 있다. 이 경우 결과 발생 시점의 실행행위만으로는 책임을 특정하기 어렵다. 그러나 해당 시스템의 설계자가 위험 평가 알고리즘을 특정 방식으로 구성하였다면 설계 단계에서의 통제가 문제될 수 있고, 운영자가 데이터 입력 및 모델 선택에 관여하였다면 운영 단계에서의 통제가 문제될 수 있으며, 감독기관이 시스템 검증을 소홀히 하였다면 감독 단계에서의 통제 실패가 문제될 수 있다. 이와 같이 자율적 시스템이 개입된 위험환경에서는 책임귀속의 기준이 개별 실행행위에 국한될 수 없으며, 위험형성과정 전반에 대한 통제 가능성의 분포를 중심으로 재구성될 필요가 있다. 이는 앞서 제시한 실제적 통제 기준이 구체적 상황에서 책임귀속 판단의 기준으로 기능할 수 있음을 보여준다.

4. 실제적 통제 기준의 판단구조

이상과 같이 책임정당화의 기준을 단순한 실행행위가 아니라 위험형성과정에 대한 실제적 통제 가능성에서 파악할 경우, 자율적 시스템이 개입된 현대적 위험환경에서 형사책임 귀속의 판단구조는 종래와 다른 방식으로 재구성될 필요가 있다. 이는 책임판단의 출발점을 결과 발생 직전의 물리적 행위에 두는 것이 아니라, 해당 위험이 어떠한 구조 속에서 형성되었으며, 그 과정에 대하여 누가 실질적인 개입가능성과 조정가능성을 보유하고 있었는가에 두는 것을 의미한다. 이때 책임귀속의 판단은 앞서 제시한 통제 가능성 기준에 비추어 이루어져야 하며, 개별 행위자의 관여 양상은 위험형성 구조에 대한 통제 지위의 정도에 따라 평가된다.

예컨대 자율주행 시스템이 탑재된 차량에서 사고가 발생한 경우, 전통적인 접근은 충돌 순간 차량을 직접 조작한 자 또는 긴급회피를 하지 않은 자를 중심으로 책임을 검토한다. 그러나 고도 자동화 환경에서는 사고의 원인이 단일한 조작행위에 환원되지 않고, 시스템의 설계 방식, 감시의 배치, 개입 권한의 설정, 운용 과정에서의 관리 수준 등 사전적 통제구조 속에서 형성되는 경우가 많다. 이 경우 책임판단의 핵심은 누가 마지막으로 차량을 조작하였는가가 아니라, 누가 위험형성의 구조를 설정하거나 이를 중단·수정할 수

있는 지위에 있었는가에 있다.

이러한 판단은 해당 행위자가 위험구조의 형성에 실질적으로 관여하였는지, 이를 수정하거나 중단할 수 있는 권한을 보유하고 있었는지, 위험을 사전에 인식하고 개입할 수 있었는지, 그리고 위험의 방향에 결정적 영향을 미칠 수 있었는지 여부를 종합적으로 고려하여 이루어진다. 따라서 책임귀속의 기준은 실행행위의 외형에 한정되지 않고, 위험형성에 대한 통제의 정도와 개입의 현실적 가능성에 기초하여 재구성될 필요가 있다.

인공지능 기반 의료판단 시스템에서도 유사한 문제가 발생한다. 진단보조 또는 치료결정 지원 시스템의 판단에 따라 환자에게 중대한 결과가 발생한 경우, 전통적 구조는 최종 판단을 내린 의료인의 행위에 책임을 집중시키는 경향이 있다. 그러나 이러한 접근은 인공지능이 판단과정에 실질적으로 개입하고 있는 상황을 충분히 반영하지 못한다. 문제는 단순히 의료인이 결정을 확정하였는가가 아니라, 해당 시스템의 설계와 학습 과정이 어떠한 위험을 내포하고 있었는지, 의료인이 그 결과를 독립적으로 검토·배제할 수 있는 여지를 보유하고 있었는지, 그리고 위험한 결과를 방지하기 위한 통제수단이 누구에게 배분되어 있었는지에 있다. 따라서 이 경우에도 책임귀속은 개별적 판단행위의 존재만으로 결정되는 것이 아니라, 앞서 제시한 통제 가능성 기준에 따라 위험형성과정 전반에 대한 통제 지위의 분포를 중심으로 평가되어야 한다.

이와 같은 개별 사례에서 확인되는 바와 같이, 실제적 통제 기준은 결과 직전의 실행주체가 아니라 위험형성과정 전반에 걸쳐 통제력을 보유한 주체를 중심으로 책임귀속을 재구성하는 기능을 수행한다. 이는 형사책임 귀속이 더 이상 “누가 직접 실행하였는가”에만 의존할 수 없고, “누가 위험의 형성과 유지, 그리고 그 중단 가능성에 실질적으로 관여하고 있었는가”를 중심으로 이루어져야 함을 의미한다.

이러한 판단구조에서 보면 정범과 공범의 구별 역시 단순히 외형적 실행분담의 유무가 아니라, 위험형성과정에 대한 통제의 정도와 지위의 차이를 중심으로 새롭게 이해될 필요가 있다.

이와 같은 관점에서 보면, 정범과 공범의 구별은 외형적 실행행위의 분담 여부가 아니라 위험형성 구조에 대한 통제의 정도에 따라 재구성될 수 있다. 예컨대, 위험구조의 기본 설계를 통하여 결과 발생의 방향과 조건을 규정한

경우에는 해당 행위자가 결과에 대한 지배적 통제력을 가진다는 점에서 정범적 책임이 인정될 수 있으며, 운영 단계에서 위험의 형성 및 전개 과정에 참여한 경우에는 공동정범 또는 과실 책임으로 평가될 수 있다. 반면, 위험을 방지할 감독의무를 부담하면서도 이를 이행하지 않은 경우에는 부진정부작 위범의 책임 구조와 결합될 수 있다.

5. 정범·공범 구조와의 접합

행위개념을 구조적 통제 지위로 재정위하는 관점은 정범·공범 구별 구조와의 정합성을 전제로 하며, 동시에 그 이론적 기초를 재해석한다. 구조적 통제 이해가 기존 정범이론을 해체한다면, 체계적 설득력을 확보할 수 없다. Roxin의 행위지배(Tatherrschaft) 이론은 정범을 구성요건 실현과정을 지배하는 자로 이해함으로써 정범성의 근거를 행위지배 개념에 두었다.³⁷⁾ 이는 행위개념 자체를 재구성하려는 이론이라기보다 정범과 공범의 구별 기준을 제시하는 데 그 이론적 초점이 있다. 따라서 이러한 이해는 기존 정범이론과 충돌하는 것이 아니라, 오히려 그 기초를 이루는 지배 개념을 구조적 통제의 관점에서 확장적으로 해석하려는 시도로 이해될 수 있다.

그럼에도 불구하고, Roxin이 지배의 본질을 ‘실현과정에 대한 통제’에서 찾았다는 점은 주목할 필요가 있다. 이러한 관점은 지배를 단순한 물리적 실행이 아니라 통제관계로 이해할 수 있는 가능성을 내포한다.

특히 실행이 분산되거나 자동화되는 환경에서는 지배의 초점이 실행의 물리적 순간에만 머물 수 없으며, 위험형성 조건을 설정·유지하는 지위가 실질적 지배의 내용으로 파악될 수 있다. 이러한 점에서 행위지배 개념은 구조적 통제 개념으로 확장될 수 있는 이론적 단서를 제공한다.

간접정범 논의 역시 실행과 통제의 분리를 보여준다. 실행자는 도구적 위치에 있을 수 있고, 실질적 지배는 다른 주체에게 귀속될 수 있다. 김성돈이 간접정범 법리의 과제를 분석하면서 우월적 의사지배의 정교화를 요구한 것은, 지배개념이 실행 중심 구조를 넘어 정교화될 필요가 있음을 전제로 한다³⁸⁾. 이와 같이 간접정범 논의는 형법이 행위자를 단순한 실행 주체로 한정

37) Roxin, 앞의 책, S. 25-31.

38) 김성돈, 앞의 논문, 14-21면.

하지 않고, 구성요건 실현과정에 대한 지배관계를 중심으로 파악하고 있음을 보여준다.

부진정부작위범 논의 또한 유사한 구조를 드러낸다. 의무위반은 물리적 실행의 부재 속에서도 형사책임을 발생시킨다. 김동률은 Roxin의 의무범 이론을 분석하면서, 행위의 본질이 물리적 사건이 아니라 규범적 지위에 있음을 지적한다³⁹⁾. 이는 행위 개념이 신체적 행위에 한정되지 않고, 일정한 의무와 그 이행 가능성이라는 규범적 구조 속에서 이해될 수 있음을 시사한다.

이러한 이론적 전개를 종합하면, 정범과 공범의 구별은 단순한 실행행위의 외형적 분담 여부에 의하여 결정되는 것이 아니라, 위험형성과정에 대한 통제의 정도와 구조적 지위에 따라 재구성될 필요가 있다.

이러한 통제 가능성 기준에 따르면, 정범과 공범의 구별은 위험형성 구조에 대한 통제의 정도에 따라 다음과 같이 유형화될 수 있다.

첫째, 위험구조의 설계 또는 핵심적 형성에 관여하여 그 방향과 구조를 결정할 경우에는 정범으로 평가될 수 있다.

둘째, 설계에는 직접 관여하지 않았으나 운영 과정에서 구조의 유지·조정에 실질적 통제력을 행사한 경우에는 공동정범으로 평가될 수 있다.

셋째, 위험형성에 일정한 영향력을 미쳤으나 그 구조를 결정하거나 수정할 수 있는 지위에 이르지 않은 경우에는 공범으로 한정될 수 있다.

넷째, 단순한 조건 제공이나 간접적 기여에 그치는 경우에는 형사책임의 귀속이 제한될 필요가 있다.

이와 같은 유형화는 통제 가능성 개념을 정범·공범 구별 구조에 구체적으로 접합시키는 기준으로 기능한다. 이하에서는 이러한 유형화를 전제로 각 범주의 내용을 보다 구체적으로 살펴본다.

특히 앞서 제시한 통제 가능성 기준에 비추어 보면, 정범은 위험구조의 형성과 유지, 그리고 그 중단 가능성에 대하여 실질적인 지배를 행사한 자로 이해될 수 있다. 이때 지배란 단순히 결과 발생 과정에 관여하였다는 의미가 아니라, 위험형성 구조의 방향과 강도를 결정할 수 있는 권한과 수단을 보유하고 있었는지를 기준으로 판단되어야 한다. 즉, 설계 단계에서의 선택, 운영 과정에서의 통제, 그리고 위험 발생 시 이를 중단하거나 수정할 수 있는 권한

39) 김동률, 「부진정부작위범의 정범기준으로서 의무범이론」, 『비교형사법연구』 제19권 제1호 (2017), 68-75면.

의 보유 여부가 지배 판단의 핵심 요소로 기능한다.

반면 공범은 그러한 통제구조에 기능적으로 결합하여 일정한 영향력을 미치지만, 그 구조 전체를 결정하거나 변경할 수 있는 지배적 지위에는 이르지 않는 자로 파악될 수 있다. 공범은 위협형성 과정에 기여하지만, 그 기여는 구조 전체의 방향을 좌우하는 수준에는 미치지 않는다는 점에서 정범과 구별된다. 이러한 기능적 결합은 정보 제공, 부분적 실행 참여, 보조적 역할 수행 등 다양한 형태로 나타날 수 있으며, 그 기여의 정도에 따라 책임의 범위 역시 달라질 수 있다.

이와 같은 구별은 단순한 영향력과 구조적 지배를 구분함으로써, 책임의 범위를 합리적으로 한정하는 기능을 수행한다. 특히 결과 발생에 일정한 인과적 기여가 존재한다는 사정만으로 정범성을 인정하는 것을 방지하고, 위협형성 구조에 대한 실질적 통제력을 가진 자에게 책임을 집중시키는 효과를 갖는다. 이는 형사책임의 개인책임 원칙을 유지하면서도, 복잡한 구조적 위험환경에서 책임의 분산과 공백을 동시에 방지하는 역할을 한다.

나아가 이러한 구조는 책임의 정도를 구별하는 기준으로도 기능할 수 있다. 즉, 위협형성 구조에 대한 지배의 정도가 클수록 책임의 강도 역시 강화될 수 있으며, 반대로 단순한 기능적 결합에 그치는 경우에는 제한된 범위에서 책임이 인정될 수 있다. 이는 정범과 공범의 구별이 단순한 형식적 분류를 넘어, 책임의 질적 차이를 반영하는 기준으로 작용할 수 있음을 의미한다.

이러한 점에서 형법은 이미 실행과 지배, 행위와 의무를 구별하는 이론적 토대를 내포하고 있으며, 이러한 흐름은 행위 개념을 통제 관계의 관점에서 재구성할 수 있는 가능성을 보여준다.

6. 객관적 귀속과 행위단계의 실질화

객관적 귀속 이론에 대한 과도한 의존은 행위단계를 형식화하고 귀속단계를 비대화시키는 문제를 발생시킬 수 있다. 인공지능 환경에서 객관적 귀속 이론을 확장하여 모든 문제를 귀속단계에서 해결하려는 경향이 나타난다. 그러나 이는 귀속단계의 기능을 과도하게 확장시키고, 행위단계를 상대적으로 형식화하는 결과로 이어질 수 있다. 단계적 범죄론 체계의 기능적 분화는 이로 인해 약화될 가능성이 있다.

객관적 귀속 이론은 허용되지 않은 위험의 창출과 그 실현 여부를 중심으로 결과귀속을 판단한다⁴⁰⁾. 그러나 위험창출 요건은 구성요건적 행위 해석과 단절되어 있지 않다. 김성돈은 위험창출이 구성요건적 ‘행위’의 해석과 결부될 수 있음을 지적한다⁴¹⁾. 이는 위험형성의 평가가 귀속단계에만 속하는 것이 아님을 의미한다.

행위개념을 구조적 통제 이해로 재정위할 경우, 행위단계는 위험형성 구조에 대한 통제 지위를 평가하는 단계로 기능한다. 귀속단계는 그 위험이 구체적 결과로 실현되었는지를 판단한다. 책임단계는 통제 가능성과 비난가능성을 검토한다. 이와 같은 기능적 재배치는 각 단계의 역할을 새롭게 창출하는 것이 아니라, 기존에 분산되어 있던 판단 요소를 단계별로 재배치함으로써 기능적 중복과 과잉을 해소하는 데 그 의의가 있다. 따라서 이는 단계적 범죄론 체계를 해체하는 시도가 아니라, 오히려 각 단계의 기능을 명확히 분화함으로써 체계적 정합성을 강화하려는 작업으로 이해될 수 있다. 이러한 재배치는 앞서 제시한 통제 가능성 기준을 행위단계, 귀속단계 및 책임단계 전반에 걸쳐 분산적으로 적용하는 것을 의미한다.

7. 체계적 합의

인공지능 환경은 형법 체계 외부에서 전혀 새로운 원리를 요구한다기보다, 기존 체계 내부의 구조적 긴장을 보다 명확하게 드러낸다. 위험이 이미 규범화된 이상, 행위개념 역시 그에 상응하는 구조로 이해될 필요가 있다.

행위를 위험형성 구조에 대한 통제 지위로 이해할 때, 행위·위험·책임은 분절된 단계가 아니라 통제 가능성을 중심으로 보다 유기적으로 연결될 수 있다. 이러한 재구성은 복잡한 기술적 환경에서 책임 귀속의 기준을 보다 명확하게 제시할 수 있다는 점에서 실질적 적용 가능성을 갖는다.

인공지능은 이 재정렬의 필요성을 가장 선명하게 드러내는 사례일 뿐이다. 문제는 기술 그 자체가 아니라, 위험형성 구조와 책임정당화 사이의 이론적 불균형이다. 행위개념의 재정위는 이러한 불균형을 정리하는 체계 내부의 작업에 해당한다. 결국 이와 같은 논의는 행위·위험·책임을 분절된 단계가 아니

40) Roxin, 앞의 책, § 11 Rn. 39-45.

41) 김성돈, 앞의 논문, 19-23면.

라 통제 가능성을 중심으로 연결된 구조로 이해할 수 있는 가능성을 보여준다. 이때 통제 가능성은 단순한 이론적 개념이 아니라, 구체적 책임귀속 판단에서 적용되는 실질적 기준으로 기능한다.

특히 이러한 재정렬은 책임 귀속의 기준을 단순한 실행행위 중심에서 벗어나, 위험형성 구조를 실질적으로 통제한 행위자에게로 이동시킨다는 점에서 구체적 의미를 갖는다. 이는 인공지능과 같이 결과 발생이 인간의 직접적 실행과 분리되는 상황에서도 책임 귀속의 기준을 일관되게 유지할 수 있게 하며, 책임 공백 또는 과잉 귀속의 문제를 동시에 완화하는 방향으로 기능할 수 있다. 나아가 이러한 접근은 책임 귀속의 기준을 구조적 통제 가능성에 따라 정교화함으로써, 복잡한 위험환경에서도 일관된 책임 판단을 가능하게 할 수 있다는 점에서 정책적 함의를 갖는다.

VI. 형사정책적 함의

1. 책임귀속 기준의 재정립

앞서의 논의를 통해 확인할 수 있듯이, 인공지능 환경은 형사책임의 귀속 기준을 단순한 물리적 실행행위에만 의존하는 방식으로는 충분히 설명하기 어렵다는 점을 드러낸다. 특히 위험이 설계·조직·운영·감독과 같은 다층적 구조 속에서 형성되는 경우, 결과를 직접 야기한 실행행위만을 기준으로 책임을 귀속시키는 전통적 접근은 그 설명력을 점차 상실하게 된다. 이러한 상황에서는 책임 귀속의 기준이 실행 자체가 아니라, 해당 위험을 행위자가 통제할 수 있었는지 여부에 대한 평가와 보다 밀접하게 연결될 필요성이 제기된다.

이러한 변화는 단순히 책임 판단의 기준을 이동시키는 것에 그치지 않고, 형사책임의 정당화 구조 자체를 재검토하게 만든다. 전통적으로 실행행위는 책임 귀속의 출발점으로 기능해 왔으나, 위험이 구조적으로 형성되는 환경에서는 그 출발점이 실행이 아닌 통제 가능성으로 이동할 수 있다. 이는 형사책임이 결과 발생이라는 사실적 계기에 기초하는 것이 아니라, 위험형성에 대한 규범적 관여 가능성에 기초한다는 점을 보다 분명하게 드러낸다.⁴²⁾

이러한 맥락에서 본 논문이 제시하는 ‘구조적 통제’란, 단순한 실행행위에 대한 지배가 아니라, 위험형성에 영향을 미치는 설계·데이터 구성·운영·감독 등의 조건을 설정하거나 유지할 수 있는 규범적 지위를 의미한다. 이러한 의미에서 구조적 통제는 단순한 이론적 개념이 아니라, 특정 행위자가 위험형성에 실질적으로 관여하였는지를 판단하기 위한 책임귀속 기준으로 기능한다.

특히 이러한 재정립은 위험형성이 실행 이전의 구조적 조건 속에서 이루어지는 경우, 단순히 결과를 직접 발생시킨 실행자를 중심으로 책임을 귀속시키는 기존 접근과 달리, 위험구조의 형성과 유지에 실질적으로 관여한 행위자에게 책임을 귀속시킬 수 있는 기준을 제공한다. 이는 복잡한 기술적·조직적 환경에서 책임 귀속의 왜곡 가능성을 완화하고, 책임 판단의 실질적 타당성을 확보하는 데 기여한다. 특히 이러한 기준은 결과 발생이 인간의 직접적 실행과 분리되는 경우에도, 위험구조의 형성과 유지에 실질적으로 관여한 행위자에게 책임을 귀속시킬 수 있도록 함으로써 책임 공백의 문제를 완화한다. 이는 결국 책임 귀속 판단의 초점을 실행행위의 존재 여부가 아니라, 특정 행위자가 위험형성 과정에 대하여 어떠한 통제 가능성을 보유하고 있었는지에 두어야 함을 의미하며, 이러한 기준은 수사 및 재판 과정에서 그 판단의 방향을 제시하는 해석론적 지침으로 기능할 수 있다.

2. 범죄론 체계의 기능적 재조정

전통적인 범죄론 체계에서 행위단계는 물리적 실행을 전제로 한 형식적 요건으로 이해되어 왔고, 위험의 평가는 주로 객관적 귀속 단계에서 집중적으로 이루어져 왔다. 그러나 인공지능 환경에서와 같이 위험형성이 구조적으로 이루어지는 경우, 이러한 단계 구분은 행위단계의 형식화와 귀속단계의 비대화라는 기능적 긴장을 드러낸다. 이로 인해 범죄론 체계의 단계적 분화가 본래 의도한 기능을 충분히 수행하지 못하는 상황이 발생할 수 있다.

이러한 맥락에서 행위단계를 단순한 사실적 전제로 이해하기보다, 위험형성 구조에 대한 통제 지위를 평가하는 단계로 재해석할 수 있다. 이에 따라 귀속단계는 위험이 구체적 결과로 실현되었는지 여부를 중심으로 기능하고,

책임단계는 통제 가능성과 비난가능성에 대한 평가를 중심으로 구성될 수 있다. 이러한 재조정은 기존 체계를 해체하는 것이 아니라, 각 단계의 기능을 보다 명확히 구분하는 방향으로 이해될 수 있으며, 단계 간 기능 중첩 문제를 완화하는 효과를 가질 수 있다.⁴³⁾

나아가 이러한 기능적 분화는 위험형성과 책임귀속 사이의 대응관계를 보다 명확하게 드러내고, 책임 판단이 특정 단계에 집중되는 경향을 완화하는 방향에서 범죄론 체계 각 단계의 기능을 재정렬하는 해석론적 의의를 갖는다.

3. 형사책임 정당화 구조의 명확화

행위를 단순한 신체적 사건이 아니라 규범적 의미를 지닌 개념으로 이해하는 관점은 형사책임의 정당화 구조를 보다 명확하게 한다. 형사책임은 결과 발생이라는 사실 그 자체에 기초하는 것이 아니라, 특정 행위자에게 그 결과를 귀속시키는 것이 정당한지에 대한 규범적 판단에 기초한다. 이러한 점에서 행위 개념은 물리적 실행에 한정될 수 없으며, 행위자의 규범적 지위와 선택 가능성을 반영하는 방식으로 이해될 필요가 있다.

특히 통제 가능성은 단순한 사실적 영향력의 문제가 아니라, 행위자가 특정 위험을 회피하거나 조정할 수 있었는지에 대한 규범적 평가를 포함한다. 이는 형사책임이 단순한 결과 책임이 아니라 비난 가능성에 기초한 책임이라는 점을 강조하며, 형사책임의 정당화가 행위자의 통제 가능성과 도덕적 지위에 근거한다는 기존 논의와도 조응한다.⁴⁴⁾ 나아가 구성요건 실현과정에 대한 지배를 중심으로 정범성을 설명하는 이론 역시 행위의 본질을 통제의 관점에서 파악하고 있음을 보여주며, 이는 행위개념의 구조적 이해와 이론적으로 정합적인 방향을 형성한다.⁴⁵⁾ 따라서 통제 가능성은 형사책임 정당화의 핵심 기준으로, 비난가능성 판단의 구체적 내용을 구성하는 실질적 지침으로 기능할 수 있다.

43) Roxin, 앞의 책, § 11 Rn. 39-45.

44) Fletcher, 앞의 책, 415-418면; Husak, 앞의 책, 78-80면.

45) Roxin, 앞의 책, § 11 Rn. 39-45; 김성돈, 앞의 논문, 19면.

4. 인공지능 환경에서의 형사정책적 의미

인공지능 환경에서 반복적으로 제기되는 이른바 ‘책임 공백’ 문제는 새로운 책임 주체의 도입 필요성으로 이해되기보다는, 기존 형법 체계가 전제하고 있는 책임 귀속 기준의 해석 문제로 재구성될 수 있다. 특히 위험형성 구조가 복잡하게 분산되는 상황에서는 책임의 공백이 발생한다기보다, 책임 귀속 기준이 충분히 정교하게 적용되지 못하는 문제가 드러난다고 볼 수 있다.

이러한 관점에서 문제의 핵심은 인공지능 자체의 책임능력 여부에 있다기보다, 위험형성 구조를 사실상 설정하거나 유지할 수 있었던 지위가 누구에게 있었는지를 어떻게 평가할 것인가에 있다.

이러한 접근은 인공지능 시스템의 작동 과정에서 발생하는 책임 공백을 새로운 책임 주체의 도입 없이도 설명할 수 있게 하며, 설계자·운영자·관리자 등 위험구조에 실질적으로 관여한 주체들 사이에서 책임 귀속의 기준을 보다 정교하게 설정할 수 있게 한다.

이는 형법 체계가 새로운 기술 환경에 대응하기 위하여 전혀 새로운 원리를 도입해야 함을 의미하는 것이 아니라, 기존 체계가 내포하고 있던 통제와 책임의 관계를 보다 정교하게 해석할 필요성을 시사한다. 이러한 관점에서 인공지능은 새로운 문제를 창출한다기보다는, 기존 형법 체계 내부에 존재하던 구조적 긴장을 보다 선명하게 드러내는 계기로 이해될 수 있으며,⁴⁶⁾ 나아가 형사책임 문제를 새로운 책임주체의 도입이 아니라, 기존 책임 귀속 기준의 정교화를 중심으로 접근할 필요성을 시사한다.

VII. 결론

본 논문은 형법상 행위개념이 범죄론 체계의 출발점으로 위치 지워져 왔음에도 불구하고, 그 내부 구조가 여전히 실행 중심 이해에 머물러 있다는 점을 문제로 제기하였다.

인과적 행위론, 목적적 행위론, 행위지배 이론 및 객관적 귀속 이론은 각각

46) Matthias, Andreas, “The Responsibility Gap: Ascribing Responsibility for the Actions of Learning Automata,” *Ethics & Information Technology* 6(3) (2004), 175-183면.

행위개념에 규범적 요소를 도입하며 발전해 왔으나, 실행행위를 중심에 두고 있다는 점에서는 공통된 구조를 유지하고 있다. 그 결과 위험은 객관적 귀속 단계에서 규범적으로 정교화되는 반면, 행위는 여전히 물리적 실행의 계기로 이해되는 이원적 구조가 형성되어 왔다. 이러한 구조는 행위가 체계의 출발 점으로 선언되면서도, 그 규범적 밀도가 귀속 단계에 집중되는 불균형을 초래한다.

이와 같은 구조는 전통적 범죄유형에서는 일정 부분 기능할 수 있었으나, 위험이 설계·조직·운영·관리와 같은 복합적 조건 속에서 형성되는 현대 사회에서는 그 설명력이 제한된다. 특히 인공지능이 의사결정 과정에 개입하는 상황에서는 결과가 인간의 직접적 신체운동을 매개로 하지 않는 경우가 증가하며, 실행 중심 행위개념은 행위자 특정과 책임 정당화의 기준으로서 충분한 역할을 수행하기 어렵다. 이러한 문제는 인공지능의 주체성 여부에 관한 논쟁으로 환원될 수 없으며, 위험형성 구조에 대한 통제 관계를 중심으로 재구성될 필요가 있다.

이에 본 논문은 행위를 단순한 실행행위가 아니라 위험형성 구조에 대한 통제 지위로 이해할 것을 제안하였다. 이는 행위개념을 확장하거나 기존 귀속 이론을 대체하려는 시도가 아니라, 이미 규범화된 위험 개념과의 체계적 정합성을 확보하기 위하여 행위개념의 위치와 기능을 재정렬하려는 이론적 시도이다. 이러한 관점에서 행위단계는 위험형성 구조에 대한 통제 가능성을 평가하는 단계로, 귀속단계는 그 위험의 실현 여부를 판단하는 단계로, 책임단계는 통제 가능성과 비난가능성을 검토하는 단계로 각각 이해될 수 있다.

이와 같은 재구성은 기존 형법 이론과 단절되는 것이 아니라, 오히려 그 내재된 구조를 보다 일관된 방식으로 정리하는 작업에 해당한다. 정범·공범 구별, 간접정범, 부진정부작위범 이론에서 나타나는 지배, 의무, 통제 개념은 이미 행위를 단순한 물리적 사건이 아니라 규범적 구조 속에서 파악할 수 있는 가능성을 내포하고 있으며, 본 논문은 이를 체계적으로 정렬하고자 하였다. 이러한 점에서 본 논문은 개별 이론을 추가하는 것이 아니라, 기존 이론들 사이의 관계를 재구성함으로써 형법 체계의 내적 정합성을 확보하려는 시도에 해당한다.

결국 인공지능 환경은 형법 체계 외부의 새로운 원리를 요구하는 예외적 상황이라기보다는, 기존 체계 내부에 존재하던 구조적 긴장을 보다 선명하게

드러내는 계기로 이해될 수 있다. 이러한 관점에서 행위개념은 더 이상 단순한 실행의 계기에 머무를 수 없으며, 위험형성 구조와 책임정당화 사이의 관계 속에서 재해석될 필요가 있다.

본 논문이 제시한 행위개념의 재정위는 형법 체계에서 행위·위험·책임의 관계를 통제 가능성을 중심으로 재구성하려는 이론적 시도이다. 이는 행위개념을 단순한 출발점에서 책임정당화의 실질적 기준으로 전환시키고, 위험과 행위 사이의 구조적 단절을 해소하려는 점에서 본 논문의 핵심적 기여에 해당한다. 이러한 관점은 형사책임 귀속의 기준을 단순한 실행행위 중심에서 벗어나, 위험형성 구조에 대한 통제 가능성을 중심으로 재정립할 필요성을 제시한다는 점에서 이론적 의미를 갖는다. 나아가 이러한 접근은 인공지능을 비롯한 기술 환경의 변화 속에서 형사책임의 기준을 보다 정교하게 설정하기 위한 이론적 토대를 제공한다.

특히 이러한 재구성은 통제 가능성을 단순한 이론적 개념이 아니라, 구체적 책임귀속 판단에서 적용되는 기준으로 정식화한다는 점에서 의미를 갖는다. 이 기준에 따르면, 책임귀속은 단순한 영향력의 존재가 아니라 위험형성 구조에 대한 실질적 지배의 정도에 따라 결정되며, 이를 통하여 책임의 범위가 과도하게 확장되는 것을 방지할 수 있다.

또한 책임은 위험형성 구조에 대한 실질적 통제 가능성이 인정되는 범위로 한정되며, 단순한 영향력이나 간접적 기여에 그치는 경우에는 책임의 중심적 근거로 작용하지 않는다. 나아가 이러한 기준은 위험을 예견하고 이를 통제할 수 있었는지 여부를 중심으로 과실 판단과도 연결됨으로써, 형사책임의 정당화 구조를 보다 일관된 방식으로 설명할 수 있게 한다. 이러한 점에서 본 논문이 제시하는 행위개념의 재정위는 단순한 개념 재구성에 그치지 않고, 형사책임 귀속 판단의 실질적 기준을 제시한다는 데 그 의의가 있다.

| 참고문헌 |

I. 국내문헌

- 김동률, 「부진정부작위범의 정범기준으로서 의무범이론—Roxin의 이론을 중심으로」, 『비교형사법연구』 제19권 제1호, 2017.
- 김성돈, 「객관적 귀속이론과 구성요건에 해당하는 ‘행위’의 실체요건」, 『형사법연구』 제34권 제3호, 2022.
- 김성돈, 「간접정범에 관한 대법원 법리와 형법이론학의 과제」, 『형사법연구』 제35권 제3호, 2023.
- 권영법, 「형법상 행위론에 대한 비판적인 고찰—종래의 행위론에 대한 검토와 통합적 행위론의 제안을 중심으로」, 『저스티스』 통권 제138호, 2013.
- 박광민·백민제, 「인공지능 로봇의 범죄주체성과 형사책임의 귀속」, 『인하대학교 법학연구』 제20집 제4호, 2017.
- 이인곤·강철하, 「인공지능 로봇의 형사범이론 체계에 관한 일고—범죄능력·형사책임능력을 중심으로」, 『법학연구』 제18권 제3호, 2018.
- 정영일, 「목적적 행위론의 형법철학적 의미」, 『형사법학』 제22권 제2호, 2010.
- 조병선, 「비교법적 관점에서 본 한국 환경형법의 인과관계와 행위자의 특징」, 한·터키 국제학술대회 발표논문, 2013.
- 허 황, 「인공지능과 형법상 행위론」, 『법학연구』 제25권 제3호, 2025.

II. 외국문헌

- Fletcher, George P., Rethinking Criminal Law. Boston: Little, Brown, 1978.
- Husak, Douglas, Philosophy of Criminal Law. Totowa: Rowman & Littlefield, 1987.
- Husak, Douglas, Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law, Oxford: Oxford University Press, 2008.

- Matthias, Andreas, "The Responsibility Gap: Ascribing Responsibility for the Actions of Learning Automata," *Ethics & Information Technology* 6(3) (2004).
- Roxin, Claus, *Criminal Law: General Part*, Vol. I. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Roxin, Claus, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, Bd. I, 4. Aufl., München: C.H. Beck, 2006.
- Roxin, Claus, *Täterschaft und Tatherrschaft*, 8. Aufl., Berlin: de Gruyter, 2015.
- Roxin, Claus, "Zur objektiven Zurechnung," *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft* 74 (1962).
- Welzel, Hans, *Das deutsche Strafrecht*, 11. Aufl., Berlin: de Gruyter, 1969.

<Abstract>

The Transformation of Criteria for Attributing Criminal Responsibility in Modern Risk Structures - From an Act-Centered to a Control-Based Approach -

Ae Ri Choi* · Yang Koo Kang**

This article begins from the observation that traditional criteria for attributing criminal responsibility may reveal certain limitations in modern risk structures shaped by technological mediation, such as autonomous driving systems and artificial intelligence. Conventional criminal law has understood “action” primarily as a bodily movement controlled by will, and has structured responsibility around the execution of such acts directly linked to the occurrence of harmful results. However, in this framework, while the normative evaluation of risk is largely carried out at the stage of objective attribution, action itself tends to remain understood as the physical point of execution. This gives rise to a structural imbalance in which the action stage is reduced to a formal prerequisite, while the substantive content of responsibility is concentrated at the attribution stage.

Although this structure has functioned to a certain extent in traditional types of offenses, its explanatory scope may become limited in situations where risk is formed through complex and multi-layered conditions such as design, organization, operation, and supervision. In particular, where artificial intelligence substantively intervenes in decision-making processes, the occurrence of results is increasingly

* Ph.D. in law, Attorney at Law (US)

** Ph.D. in engineering, Adjunct Professor at Sungkyunkwan University.

detached from direct human bodily movements, making it difficult to adequately explain the relationship between risk formation and responsibility solely on the basis of execution-centered attribution.

Against this background, this article suggests that the criteria for attributing responsibility should be reconsidered not only in terms of execution, but also from the perspective of practical control over the process of risk formation. In this regard, control is positioned not as a subsidiary consideration, but as a central criterion in the assessment of responsibility, and is structured as a composite judgment that takes into account multiple factors, including involvement in design, possession of control mechanisms, the capacity to recognize risk, and the scope of influence. Under this approach, responsibility should be determined not by the mere existence of influence, but by the degree of substantive dominance over the structure of risk formation, and should be limited to situations in which meaningful control can be established.

Furthermore, this control-oriented approach does not depart from existing criminal law theory, but can be understood as a reordering and extension of control-related concepts already present in doctrines such as Roxin's theory of control over the act (Tatherrschaft), indirect perpetration, and omission liability. From this perspective, the distinction between principals and accomplices may also be reinterpreted not solely on the basis of the external division of acts, but in terms of the degree and structural position of control over the process of risk formation. In addition, this framework can be connected to the assessment of negligence by linking responsibility to the foreseeability of risk and the availability of control, thereby contributing to a more coherent account of the justification of criminal responsibility.

In conclusion, this article proposes to reconsider the concept of action from the perspective of control over risk structures, and to complement and reorganize the criteria for attributing criminal responsibility from an execution-centered model toward a control-oriented framework.

In doing so, it aims to provide a theoretical direction for more precisely defining the scope and standards of responsibility in response to technological transformations.

Key Words | Concept of Action, Control over Risk Formation, Attribution of Responsibility, Principal and Accomplice, Negligence, Objective Attribution, Artificial Intelligence